

건설업에서의 구조적 임금체불: 누구에게 책임을 물어야 하는가?

○ 대법원 2025. 12. 11. 선고 2025도3844 판결

문 준 혁(성신여자대학교 법과대학 조교수)

[판결요지]

① 근로기준법 제44조의2의 문언과 형식, 입법 취지 등에 비추어 보면, 근로기준법 제44조의2에 따라 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급할 책임을 부담하는 주체는 ‘직상 수급인’으로 한정된다. 여기서 ‘직상 수급인’이란 건설산업기본법 제2조 제7호에 따른 건설사업자로서, 건설업에서 사업이 2차례 이상 도급이 이루어진 경우에 같은 호에 따른 건설사업자가 아닌 하수급인에게 하도급을 준 수급인에 해당하는 ‘사업주’를 의미한다.

② 근로기준법 제115조는 ‘사업주의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 해당 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 제109조 제1항, 제44조의2의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 사업주에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다’라고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 근로기준법 제109조 제1항의 벌칙 규정이 적용되는 직상 수급인이 아니면서 근로기준법 제44조의2에 따른 직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자가 있을 때 벌칙 규정의 실효성을 확보하기 위하여 적용대상자를 해당 업무를 실제로 집행하는 자까지 확장하여 그 행위자도 아울러 처벌하려는 데 있다. 이러한 양벌규정은 해당 업무를 실제로 집행하는 자에 대한 처벌의 근거 규정이 된다.

평석 대상판결의 개요는 다음과 같다. 이 사건 피고인은 A회사(건설업체)의 사내이사인데, 건물신축 공사 중 철근콘크리트 공사를 A회사의 이름으로 약 8억원에 하도급 받은 다음, 그 중 목공공사 부분을 건설업 등록을 하지 않은 하수급인 B(개인사업자)에게 7억2천만원에 하도급하여 공사를 완료하였다. 그러나 정작 하수급인 B가 목공공사에 사용한 근로자 41명은 임금 약 8천4백만원을 지급받지 못하였고, 이에 검사는 하수급인 B와 피고인을 근로기준법 제44조의2¹⁾ 제1항 위반으로 기소하였다.

그런데 검사는 왜 A회사의 대표이사가 아니라 피고인을 기소하였을까? 바로 A회사의 실경영자가 피고인이라고 판단하였기 때문이다. 이러한 판단을 뒷받침하는 구체적 사정으로, A회사의 대표이사는 피고인의 요청에 따라 하도급 계약서 작성, 보증서 발급 등에 형식적으로만 관여하였고, 공사의 재하도급 및 하도급 근로자의 감독, 공사 전반의 비용 지출 등의 업무 또한 피고인이 도맡아서 처리하였고, 공사대금은 A회사를 통해 지출되기는 하였으나 그 지급 금액, 시기, 방법 등도 피고인이 결정하였고, 자금 집행 또한 피고인의 요청에 따라 그대로 이루어졌음이 대상판결에서 인정되었다.

다만 피고인을 근로기준법 제44조의2 제1항 위반으로 처벌하기 위해서는 한 가지 해결되어야 하는 쟁점이 있었는데, 바로 피고인이 위 조항의 수급자인 ‘직상 수급인’에 해당한다고 볼 수 있는지 여부였다. 이 점에 대하여 대상판결은 위 조항에서 말하는 직상 수급인이란 “건설산업

1) 근로기준법 제44조의2(건설업에서의 임금 지급 연대책임)

① 건설업에서 사업이 2차례 이상 「건설산업기본법」 제2조제11호에 따른 도급이 이루어진 경우에 같은 법 제2조제7호에 따른 건설사업자가 아닌 하수급인이 그가 사용한 근로자에게 임금(해당 건설공사에서 발생한 임금으로 한정한다)을 지급하지 못한 경우에는 그 직상 수급인은 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급할 책임을 진다.

② 제1항의 직상 수급인이 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자가 아닌 때에는 그 상위 수급인 중에서 최하위의 같은 호에 따른 건설사업자를 직상 수급인으로 본다.

근로기준법 제109조(벌칙)

① ...제44조의2...을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

기본법 제2조 제7호에 따른 건설사업자로서, 건설업에서 사업이 2차례 이상 도급이 이루어진 경우에 같은 호에 따른 건설사업자가 아닌 하수급인에게 하도급을 준 수급인에 해당하는 ‘사업주’를 의미한다”라고 판시하였다(판시사항 ①). 이러한 판시의 취지대로라면, 형식적으로 볼 때 이 사건 목공공사의 도급은 A회사의 이름으로 이루어졌으므로, A회사의 사내이사에 불과한 피고인을 사업주인 직상수급인으로 보아 처벌할 수는 없게 된다.²⁾

그래서 피고인은 무죄인가? 대법판결은 피고인에게 유죄(징역 6개월에 집행유예 2년 및 80시간의 사회봉사)를 선고한 원심을 확정하였다. 검사가 원심에서 예비적 공소사실로 추가한 주장, 즉 피고인이 근로기준법 제44조의2 제1항에서 말하는 ‘직상 수급인’은 아니지만, 근로기준법 제115조의 양벌규정³⁾의 취지(벌칙 규정의 실효성 확보)와 규정 내용(“그 행위자를 벌하는 외에”)에 비추어 보면 피고인을 ‘근로기준법 제44조의2에 따른 직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자’로 보아 처벌할 수 있다는 주장을 수긍한 것이다(판시사항 ②).⁴⁾ 이를 이른바 ‘양벌규정의

2) 이 사건 원심은 피고인이 A회사의 실경영자 지위에 있다는 점이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없어 피고인을 직상수급인으로 보아 처벌할 수는 없다고 보았는데, 대법원은 이러한 원심의 판단이 정당하다고 보았다.

3) 근로기준법 제115조(양벌규정)

사업주의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 해당 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 제107조, 제109조부터 제111조까지, 제113조 또는 제114조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 사업주에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 사업주가 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 나아가 대법판결은 여기에서 말하는 ‘직상 수급인의 업무를 실제로 집행하는 자’란 “‘건설업 등록이 되어 있지 않은 하수급인에게 건설공사를 하도급하는 업무’ 및 ‘하도급대금 지급 등 해당 하도급과 관련하여 자금을 집행하는 업무’ 등에 관하여 사실상 행위자 자신의 독자적인 판단이나 권한에 의하여 그 업무를 수행할 수 있는 사람을 의미한다.”라고 판시한 다음, “여기서 그 행위자에게 독자적인 판단이나 권한이 있는지는, 근로기준법 제44조의2의 입법 취지를 염두에 두고, 직상 수급인과 행위자의 관계 및 행위자의 지위, 하도급계약의 체결 경위, 하도급대금과 하수급인이 사용한 근로자

역(逆)적용’ 이론이라고 하는데, 이것이 과연 죄형법정주의의 요청에 비추어 볼 때 허용되는 것인지,⁵⁾ 실무상 부작용은 없었는지⁶⁾ 등은 이 글에서는 자세히 다루지 않기로 한다. 다만 대상판결은 그간 산업안전보건법 등에서 활용되던 양벌규정의 역적용 이론을 근로기준법 위반죄에 적용한 최초의 사례로 보아기는 한다.⁷⁾

피고인의 책임을 인정하였다는 점만 놓고 보면, 대상판결은 근로기준법 제44조의2 제1항의 문언이 갖는 한계를 양벌규정의 역적용을 통하여

에 대한 임금 지급 방식, 이와 관련된 자금의 집행 권한을 비롯하여 해당 하도급과 관련하여 행위자에게 부여된 권한의 내용과 범위, 하도급으로 발생한 경제적 이익의 실질적 귀속 주체 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”고 판시하였다.

- 5) 죄형법정주의의 관점에서 ‘양벌규정의 역적용’ 이론을 비판하는 견해로 강병연, “산업안전보건법상 신분법의 법인 처벌과 양벌규정에 대한 새로운 이해”, 『경희법학』 제58권 제3호, 경희법학연구소, 143~173쪽 참조. 같은 취지에서 대상판결을 비판적으로 바라보는 견해로 노호창, “법인 뒤의 개인을 벌하는 ‘마법의 지팡이’가 된 양벌규정, 형사책임의 엄격성은 안녕한가 - 대법원 2025. 12. 11. 선고 2025도3844 판결 -”, 월간 『노동리뷰』 2026년 2월호, 한국노동연구원, 93~96쪽 참조.
- 6) 최근 대법원은 “피고인 자신이 직접 형사처분이나 징계처분을 받게 될 것을 두려워한 나머지 자기의 이익을 위하여 그 증거가 될 자료를 인멸하였다면, 그 행위가 동시에 다른 공범자의 형사사건이나 징계사건에 관한 증거를 인멸한 결과가 된다고 하더라도 이를 증거인멸죄로 다스릴 수 없”고, 따라서 “여기서 말하는 ‘피고인 자신이 직접 형사처분을 받게 될 것’에는 피고인이 양벌규정에 따라 처벌받을 수 있는 법인의 업무에 관하여 행위자로서 처벌받게 될 수 있는 경우도 포함된다”라고 판시하여 하도급법 위반에 대한 공정거래위원회 조사를 앞두고 관련 자료를 PC에서 삭제한 HD현대중공업 노사협력사지원팀 임직원들에게 유죄를 선고한 원심을 무죄 취지로 파기환송하였다(대법원 2026.1.15. 선고 2024도15728 판결). 이 판시의 취지에 따르면 산업안전보건법상 양벌규정을 역적용하여 처벌받을 가능성이 있는 임직원들이 스스로를 위하여 증거를 인멸하는 경우에는 처벌할 수 없게 되는 문제가 있다.
- 7) 이는 근로기준법에서는 사용자의 개념에 사업주 외에 실제 행위에 해당하는 ‘사업의 경영담당자’ 및 ‘그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자’를 명시하고 있고, 대부분의 법규정에서 그 수급자를 사용자로 정하고 있기 때문에 굳이 이러한 논의를 할 필요가 없었기 때문이다.

바로잡아 그 실질에 맞는 책임을 묻은 것으로 보이기 는 한다. 그러나 여전히 어딘가 개운치 않다. 건설업에서의 구조적 임금체불의 책임을 묻는 작업이 피고인에서 그쳐서는 안 되기 때문이다.

먼저, A회사(내지 그 대표이사)도 이 사건 임금체불의 공범이라고 보아야 한다. 건설업계에서는 이 사건 피고인처럼 대외적으로는 면허를 가지고 있는 건설회사의 임원인 것처럼 행세하지만 실제로는 회사의 명의로 수주한 소규모 건설공사를 자기의 계산으로 독립하여 수행하는 자들을 소위 ‘부금상무’ 또는 ‘실행소장’이라고 한다. 이러한 운영구조는 소규모 범무법인에서도 활용되는 별산제(別産制) 방식이라고도 할 수 있는데, 이를 통해 공사를 실제 수행하는 자들은 건설업 면허가 없음에도 불구하고 회사의 건설업 면허를 이용하여 독자적으로 공사를 할 수 있게 되고, 건설회사는 그 반대급부로 수주한 공사에 대한 관리비 명목으로 수수료를 받으면서 동시에 각종 입찰 및 수주에 필요한 건설공사 시공실적을 쌓을 수 있다.

그러나 이는 건설사업자의 명의대여를 금지하고 있는 건설산업기본법 제21조를 우회하는 편법적인 사업방식에 불과한 것이므로,⁸⁾ 이 사건 A회사와 피고인의 관계 또한 건설공사의 도급관계라고 보는 것이 그 사업구조의 실질에 부합한다. 따라서 검사는 이 사건에서 근로기준법 제44조의2 제2항에 따라 건설사업자가 아닌 피고인(과 하수급인 B)에게 공사를 도급한 A회사(내지 그 대표이사)를 직상 수급인으로 보아 임금체불에 대한 책임을 함께 물었어야 했다.⁹⁾ 나아가 A회사도 피고인이 공사를 수주하면 관리비 명목의 금원을 제공받았으므로 이러한 사업구조 속

8) 건설산업기본법 제21조 위반 시 명의대여자와 명의차용자 및 이를 알선한 자, 그리고 이들과 공모하여 공사를 시공하게 한 건축주 모두 5년 이하의 징역 및 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있고(제95조의2), 명의대여자의 건설업 등록은 말소된다(제83조). 건설산업기본법 제21조가 금지하는 명의대여의 의미와 명의대여 여부에 대한 판단기준에 대해서는 대법원 2003. 12.26. 선고 2003도5541 판결 참조.

9) 대법판결이 원심에서는 다투어지지 않았던 쟁점인 판시사항 ①을 설시한 이유도 만약 이 사건에서 사업주에 해당하는 A회사가 같이 기소되었다면 그에게도 책임을 인정할 수도 있었다는 점을 간접적으로 보여주는 것이라고 읽힌다.

에서 직접적인 이익을 분명히 얻었고, 나아가 시공실적 확보 측면에서도 간접적인 이익을 얻었음을 고려하면 A회사에게 연대책임을 인정하는 것은 공평의 측면에서도 타당할 뿐만 아니라, 특히 임금채권 변제의 실효성 확보¹⁰⁾ 및 강행규정인 건설산업기본법 제21조의 취지를 잠탈하는 탈법적 하도급 관행의 근절을 위해서도 명의차용자에 불과한 피고인이 아니라 자력이 있는 명의대여자(건설사업자)에게도 연대책임을 물어야 한다. 이 사건 임금채불에 대한 민사적 구제가 어떻게 진행되었는지는 확인하지 못하였지만, 부디 그 사업구조의 실질에 맞는 책임이 추궁되었기를 바란다.

나아가 이 사건 임금채불이 편법적·탈법적 건설공사 하도급이라는 구조적 요인에서 비롯되었다는 점에서는 정부의 책임도 지적하지 않을 수 없다. 건설업에서 발생하는 임금채불의 구조적 문제가 반복되자 이를 해소하기 위하여 근로기준법 제44조의2와 제44조의3을 신설한 것이 거의 20년 전(2007년)의 일이다. 그럼에도 불구하고 건설업 임금채불의 규모는 점차 증가하여 2025년에는 연간 4천억원에 달하게 된 것이 과연 건설업의 일시적인 경기 위축 때문인지, 아니면 부처 간 칸막이¹¹⁾를 핑계로 삼은 감독행정의 방치 때문인지 묻지 않을 수 없는 것이다.

늦었지만 2026. 3. 12.에 국회는 일정한 업종, 금액 규모, 기간에 해당하는 사업을 도급하는 경우 도급인이 그 도급금액 중 수급인이 자신의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 해당하는 비용을 구분하여 지급하도록 하는 한편, 수급인의 임금 지급 여부도 도급인이 확인하도록 하는 ‘인건비 구분지급·지급확인제’(근로기준법 제44조의4)를 2027.1.1.부터 시행하도록 근로기준법을 개정하였다. 그리고 다단계 하도급 구조에서 하도급 근로자의 인건비를 발주자가 직접 지급하도록 현재 공공 건설공사에 활용되고 있는 하도급대금 전자지급 시스템(하도급지킴이 등) 사용의무를 건설업 뿐만 아니라 조선업 등 민간 도급사업 전반으로 확대하

10) 피고인이나 하수급인 B 같은 미등록(무면허) 건설사업자들의 경우 대부분 임금채권 변제를 위한 책임재산(자력)이 없어, 법원의 확정판결이 있어도 실질적인 변제가 불가능한 경우가 대부분이다.

11) 건설업의 불법·탈법적 하도급 과정에서 발생하는 구조적 임금채불에 대해서는 최소 3개 정부부처(노동부·국토부·공정위)가 관여할 수 있다.

는 내용의 이른바 ‘발주자 직접지급 3법(근로기준법, 건설산업기본법, 하도급법)’ 개정 방안도 논의되고 있다. 이에 대한 입법이 조속히 이루어져 매년 2조원 이상(2025년 기준 2조679억원) 발생하는 임금체불의 구조적 원인이 해소될 수 있기를 희망한다.

결국 지금까지의 모든 논의는 ‘이윤 있는 곳에 책임 있다’(Ubi emolumentum ibi onus)는 정의의 기본원칙을 복잡한 사업구조 속에서 어떻게 관철시켜 나갈 것인지에 대한 것이다. 이러쿵저러쿵 말들이 많지만, 2026. 3. 10. 부터 시행된 개정 노동조합법 제2조 제2호 후단의 본질도 바로 여기에 있다. 누군가가 마땅히 져야 할 법적 책임을 피하기 위해 형식을 가장할 때, 그 실질을 추적하여 그에 맞는 책임을 묻는 것은 노동법 연구자의 책임이기도 하다.